

<제4편 소송의 종료.제9장 당사자 행위에 의한 종료.제3절 재판상 화해>

I. 소송상 화해

1. 의의

- 소송상 화해란 소송계속 중 양 당사자가 소송물의 권리관계에 관하여 상호 양보하여 소송을 종료시키기로 하는 합의를 법원에 진술하고, 이를 조서에 기재함으로써 소송을 종료시키는 행위를 말한다. 이는 당사자의 자율적 분쟁 해결을 존중하는 처분권주의의 결과물이다.

2. 법적 성질

(1) 학설

- 사법행위설은 화해를 민법상 화해계약으로 보며 조서 기재는 그 증명방법에 불과하다고 본다. 소송행위설은 화해를 순수한 소송상 행위로 보아 사법상 실제적 하자가 있더라도 소송법적 요건만 갖추면 유효하다고 본다. 양성을 인정하는 병존설과 두 성질이 융합되었다는 취지의 무명계약설 등이 대립한다.

(2) 판례

- 대법원은 소송상 화해를 원칙적으로 소송행위로 파악한다. 따라서 사법상의 착오, 사기, 강박 등을 이유로 화해의 효력을 다툴 수 없으며, 오로지 재심 사유에 해당하는 중대한 결함이 있는 경우에만 준재심의 소를 통해 그 효력을 다툴 수 있다는 입장을 견지하고 있다.

(3) 검토

- 소송절차의 안정성과 명확성을 고려할 때 소송행위설이 타당하다. 일단 조서가 작성되면 확정판결과 동일한 효력이 발생하므로 실제법상의 사유로 그 효력을 쉽게 부정하는 것은 법적 안정성을 해칠 우려가 크기 때문이다.

(4) 논의의 실익

- 사법행위설에 의하면 민법상의 취소·해제 규정이 적용될 수 있으나, 소송행위설에 의하면 이러한 사법상 규정의 적용이 배제되고 소송법적 구제 수단인 준재심으로만 다툴 수 있게 된다.

3. 성립요건

(1) 당사자에 대한 요건

- 당사자는 유효한 소송행위 능력을 갖추어야 한다. 소송대리인의 경우 민사소송법 제90조 제2항에 따른 화해에 관한 특별수권이 반드시 있어야 한다. 또한 당사자 본인이나 대리인이 기일에 직접 출석하여 화해의 의사를 표시해야 한다.

(2) 소송물에 대한 요건

- 당사자가 임의로 처분할 수 있는 사적 권리관계여야 한다. 직권탐지주의가 적용되는 가사소송이나 공익적 성격이 강한 행정소송 중 일부 절차에서는 원칙적으로 화해가 허용되지 않는다. 또한, 반사회적 내용이거나 강행법규 위반인 경우 법원은 화해를 수리할 수 없다.

(3) 시기

- 소송이 계속 중인 상태라면 제1심부터 상고심까지 어느 단계에서든 가능하다. 변론기일뿐만 아니라 변론준비기일에서도 행해질 수 있다.

(4) 방식

- 변론기일 또는 변론준비기일에서 당사자 쌍방이 출석하여 구술로 합의 내용을 진술해야 한다. 법원사무관 등은 이 진술 내용을 화해조서에 기재하여야 하며, 조서의 기재가 완료됨으로써 화해가 성립한다.

4. 효과

(1) 소송종료효

- 화해조서가 작성되면 소송은 그 즉시 종료된다. 소송물 전부에 관한 화해라면 소송 전체가 소멸하며, 일부 화해라면 해당 부분에 대해서만 소송이 종료된다.

(2) 확정판결과 동일한 효력 - 기판력

- 민사소송법 제220조에 따라 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 기판력이 발생하므로 동일한 청구에 대하여 다시 소를 제기할 수 없으며, 후행 소송의 법원은 화해의 내용과 모순되는 판단을 할 수 없다.

(3) 확정판결과 동일한 효력 - 집행력과 형성력

- 화해조서에 급부의무가 포함된 경우 이는 독립된 집행권원이 되어 강제집행을 할 수 있다. 또한, 형성소송에서의 화해는 법률관계를 직접 변동시키는 형성적 효력을 가진다.

(4) 실제법상 화해의 창설적 효력인정 여부

- 판례는 소송상 화해에도 민법 제733조의 창설적 효력을 인정한다. 화해가 성립하면 종전의 법률관계를 바탕으로 한 권리 주장은 소멸하고, 화해에 의해 형성된 새로운 법률관계가 효력을 갖게 된다.

5. 소송상 화해의 효력을 다투는 절차

(1) 기속력을 다투는 방법

- 조서에 오키나 계산상의 착오 등 명백한 오류가 있는 경우에는 경정결정을 통해 수정할 수 있다.

(2) 기판력을 다투는 방법

- 화해조서에 기판력이 발생한 후에는 오로지 준재심의 소를 통해서만 다툴 수 있다. 민사소송법 제461조가 규정하는 재심 사유(대리권 흠결, 형사상 처벌받을 타인의 행위 등)가 증명되어야 화해의 효력을 부인할 수 있다.

(3) 화해조서상 의무불이행을 이유로 하는 화해해제 가부

- 소송상 화해는 소송행위이므로 사법상의 해제 규정이 적용되지 않는다. 따라서 상대방이 화해 조서상의 의무를 이행하지 않는다고 하더라도 화해 자체를 해제하고 종전의 소송 상태로 복귀할 수는 없으며, 오로지 조서에 기한 강제집행만이 가능하다.

6. 화해권고결정[민소법 제225조]

(1) 의의

- 법원·수명법관 또는 수탁판사가 소송계속 중인 사건에 대하여 직권으로 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 사건의 공평한 해결을 위해 내리는 결정을 말한다.

(2) 요건

- 소송계속 중이어야 하며, 당사자의 합의가 없더라도 법원이 직권으로 적절한 해결책을 제시할 필요가 있다고 판단될 때 행해진다.

(3) 절차

- 법원이 결정서 정본을 당사자에게 송달하며, 당사자는 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의신청을 할 수 있다. 만약, 이의신청이 없거나 이의신청이 취하·각하된 경우에는 그 결정이 확정된다.

(4) 효과

- 확정된 화해권고결정은 재판상 화해와 동일하게 확정판결과 같은 효력을 가진다. 만약, 적법한 이의신청이 있으면 결정은 효력을 잃고 소송은 이전 상태로 복귀한다.

II. 제소 전 화해

1. 의의

- 제소 전 화해란 일반 민사분쟁이 소송으로 이행되는 것을 방지하기 위하여 소 제기 전에 지방법원 판사 앞에서 화해를 성립시키는 절차를 말한다. 이는 소송계속을 전제로 하지 않는다는 점에서 소송상 화해와 구별된다.

2. 법적 성질

(1) 학설

- 독립된 특별절차로 보는 견해와 사법상 합의를 공증하는 절차로 보는 견해가 대립하나, 기본적으로는 재판상 화해의 일종으로 파악한다.

(2) 판례

- 판례는 제소 전 화해조서 역시 확정판결과 동일한 효력을 가지며, 그 기판력의 범위 내에서는 실체법상 하자를 이유로 무효를 주장할 수 없다는 태도를 취한다.

(3) 검토

- 분쟁 예방이라는 목적과 집행권원 부여라는 기능을 고려할 때, 재판상 화해에 준하는 소송법적 성격을 강조하는 것이 타당하다.

3. 성립요건

- 당사자 간의 사전 화해 합의가 있어야 하며, 신청인은 상대방의 보통재판적 소재지 지방법원에 신청하여야 한다. 소송상 화해와 마찬가지로 처분 가능한 권리관계여야 하며, 강행법규 위반 등의 내용이 포함되지 않아야 한다.

4. 절차

- 화해 신청이 접수되면 법원은 기일을 정하여 당사자를 소환한다. 기일에서 양 당사자의 의사가 합치되면 화해조서를 작성한다. 만약, 일방이 출석하지 않거나 화해가 성립되지 않으면 법원은 화해 불성립으로 처리하고 사건을 종결하거나, 신청인의 신청에 의해 소송절차로 이행할 수 있다.

5. 화해조서의 효력

(1) 학설

- 무효인 화해조서의 효력에 관하여 당연무효설과 취소가능설이 대립한다.

(2) 판례

- 판례는 제소 전 화해 내용이 강행법규에 위반된다 하더라도 그것만으로 조서가 당연무효가 되는 것은 아니며, 준재심 절차에 의해 취소되지 않는 한 확정판결과 동일한 효력이 유지된다고 본다.

(3) 검토

- 법적 안정성을 위해 당연무효설보다는 준재심을 통해서만 다룰 수 있다는 판례의 입장이 타당하다.

6. 제소 전 화해를 다루는 방법 - 소송상 화해와 동일

- 제소 전 화해조서의 기판력을 부인하기 위해서는 민사소송법이 규정하는 재심 사유를 원인으로 한 준재심의 소를 제기하여야 한다. 단순한 사법상 하자만으로는 그 효력을 다룰 수 없다.

7. 제소 전 화해의 채무불이행을 원인으로 한 해제와 취소 가부 - 소송상 화해와 동일

- 제소 전 화해 역시 재판상 화해로서 소송법적 효력을 가지므로, 실체법상의 해제권 행사나 취소는 허용되지 않는다. 당사자는 조서의 내용에 따라 이행을 강제할 수 있을 뿐이다.

III. 결론

- 재판상 화해는 당사자의 양보를 통해 분쟁을 중국적으로 해결하는 제도로써, 소송경제와 당사자의 만족도를 동시에 충족시킨다. 특히, 화해조서가 확정판결과 동일한 효력을 가짐으로써 발생하는 강한 기판력과 집행력은 법적 분쟁의 조기 종결에 크게 기여한다. 그러나 그 효력이 강력한 만큼 준재심 이외의 방법으로는 다룰 수 없다는 위험성도 존재하므로, 당사자는 화해 조항을 작성함에 있어 신중을 기해야 한다. 또한, 법원은 제소 전 화해 등이 강행법규를 잠탈하는 수단으로 악용되지 않도록 실질적인 심사를 강화할 필요가 있다. 결과적으로 이 제도는 사법 자원의 효율적 배분과 실질적 정의 실현이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 필수적인 절차적 장치라 할 수 있다.